

1501011-12.2019.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... anônimas que afirmavam estar sendo realizado tráfico de drogas na região. Dado que o motociclista avançou e o carona dispensou um invólucro com 83g (oitenta e três gramas) de insumos para preparo de cocaína, os agentes foram detidos e todos se deslocaram à residência de um deles, onde foram encontrados mais 19g (dezenove gramas) dos mesmos insumos..3. Portanto, de plano, há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501011-12.2019.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501011-12.2019.8.26.0038

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS, já qualificado nos autos, como incurso nos crimes dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e 329, do Código Penal.

Notificação às fls.108.

Defesa Preliminar às fls.112/117.

Denúncia recebida às fls.118/119.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (juntadas às fls.237). A Defesa desistiu de uma testemunha e insistiu na oitiva de outra (fls.163/166).

Às fls.181 foi declarada a preclusão da oitiva da testemunha de defesa restante.

Designou-se audiência para interrogatório em que decretada a revelia do acusado

(fls.269).

Encerrada a instrução, o Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Interrogado em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls.08).

Ainda na fase investigativa, os guardas municipais declararam, em suma, terem recebido delação apócrifa informando que o réu estaria refinando e embalando cocaína em sua residência. Em diligência no local, ingressaram no imóvel apreendendo grande quantidade de drogas. Afirmaram que o acusado resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física.

Em juízo, os servidores municipais acrescentaram que o delator apócrifo residia no imóvel indicado, mas não quis se identificar, autorizando o ingresso domiciliar e deixando a porta aberta.

São as provas. A absolvição é de rigor.

Evidentemente ilegal a ação estatal.

Como se sabe, mera delação apócrifa não autoriza ingresso domiciliar forçado.

Aliás, o próprio guarda Vítor deixou claro estar ciente de que não poderia ingressar no imóvel, o que inclusive, segundo ele (aos 01min e 36 seg do vídeo de fls.237), teria sido informado ao delator.

Conforme ensina o mestre E. Magalhães Noronha, "A casa é o asilo inviolável do cidadão"; os ingleses dizem 'My house is my kingdom' (Minha casa é meu reino)." (Curso de Direito Processual Penal, 5a. Edição, editora Saraiva, 1972, p. 93)

Por ser a casa local inviolável, e sendo, porém, permitido o ingresso em situação de flagrância delitiva, a Corte Suprema andou bem ao deliberar, com repercussão geral (Tema 280) quando permitido ingresso por autoridades estatais sem mandado judicial, coibindo-se ações arbitrárias, a saber:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Assim sendo, tem-se que, no caso em apreço, o ingresso domiciliar sem mandado ESTÁ eivado de nulidade.

De fato, como os guardas deixaram claro às fls.06 e 07 (depoimentos extrajudiciais), a invasão do imóvel se deu com base exclusivamente em delação apócrifa, o que não pode ser admitido como justa causa aceitável para excluir a necessidade de autorização judicial, conforme o já mencionado precedente do E. STF.

No mesmo sentido são inúmeros os julgados de nossos Tribunais. Vejamos:

"(...) No caso em tela, os policiais deram ordem de parada aos corréus em razão de denúncias anônimas que afirmavam estar sendo realizado tráfico de drogas na região. Dado que o motociclista avançou e o carona dispensou um invólucro com 83g (oitenta e três gramas) de insumos para preparo de cocaína, os agentes foram detidos e todos se deslocaram à residência de um deles, onde foram encontrados mais 19g (dezenove gramas) dos mesmos insumos..3. Portanto, de plano, há ilegalidade na abordagem e

revista pessoal nos agentes em razão de terem como lastro somente denúncias anônimas não registradas e não sindicáveis, com o posterior ingresso forçado em domicílio fora das hipóteses legais.” (STJ, 6ª. Turma, HC 696390/SP, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgamento em 20/09/2022).

“(…) No caso em tela, os agentes policiais, após receberem denúncia anônima, deslocaram-se ao local indicado e abordaram o ora paciente, não encontrando nada de ilícito, mas ainda assim se dirigiram à sua casa, onde encontraram 198g (cento e noventa e oito gramas) de cocaína, bem como mensagens de mercancia de drogas em seu celular. 3. A violação de domicílio teve como justificativa, como visto acima, tão somente denúncia anônima, tanto que nada de ilícito foi encontrado com o agente quando da revista pessoal, circunstâncias fáticas que não autorizam a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência nem a devassa em suas mensagens de celular, acarretando a nulidade da diligência policial, porquanto não há detalhamento acerca da apreensão precedente. 4. Ademais, a alegação de autorização de entrada dos policiais pelo agente não merece acolhimento, porquanto desacompanhada de qualquer elemento probatório no mesmo sentido, salvo o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante. 5. “Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador” (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, 6ª. Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).” (STJ, 6ª. Turma, HC 734326/PR, de relatoria do Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgamento em 20/09/2022).

“(…) No presente caso, os policiais militares alegaram ter ingressado na residência onde estavam os acusados após o recebimento de informações anônimas no sentido de que pessoas haviam levado drogas que estavam anteriormente escondidas em um local que estava pegando fogo para o sobredito imóvel, sendo certo que entraram no domicílio sem o consentimento do morador e sem mandado judicial. Ademais, eles não procederam a qualquer campana ou observação da residência que lhes fornecesse mais elementos, além da sobredita informação anônima, no sentido de que havia situação de flagrante delito apta a excepcionar a inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A toda evidência, não se pode admitir que policiais militares ingressem em uma residência sem mandado judicial unicamente em razão de existir informação anônima quanto à prática de delito no local e por ela estar com as portas abertas, sem que haja qualquer circunstância concreta que indique o estado de flagrância, sendo certo a informação anônima quanto a prática do tráfico de drogas, por si só, é insuficiente para tanto. Evidente, portanto, que a apreensão das drogas na residência onde estavam os apelados constitui prova ilícita em razão da violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (…).” (TJSP, 16ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 0005189-54.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Leme Garcia. São Paulo, 13 de maio de 2019).

Em verdade, agiram muito mal os servidores municipais que, avisados de suposto tráfico e cientes de que não poderiam ingressar no imóvel (cf admitido pelo GM Vítor aos (aos 01min e 36 seg do vídeo de fls.237), deveriam ter adotados os procedimentos de legais, alertando a Polícia Civil que, após investigação e colheita de elementos idôneos, poderia pleitear autorização judicial para o ingresso forçado.

Assim, todavia, não agiram, preferindo, ao arrepio da lei, avocar poder investigativo que não possuem.

Aliás, embora não se negue validade de prisões em flagrante realizadas por Guardas Municipais, tal qual é permitido a qualquer pessoa do povo, com base no art. 301, do CPP, esse não é o caso dos autos.

De fato, como se viu acima, os guardas encetaram diligência investigativa após o

recebimento de delação apócrifa, ingressando em imóvel alheio sem a certeza visual de prática delitiva, o que é às escâncaras ilegal.

Os guardas, ainda que de boa-fé, extrapolaram suas funções, exercendo verdadeira atividade investigativa de incumbência da Polícia Civil, o que viola o princípio da legalidade estrita.

Nesse sentido, recorro que “Por Estado de direito entende-se geralmente um Estado em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que os regulam, salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para fazer com que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de poder” (BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia, tradução: Marco Aurelio Nogueira. Editora brasiliense, 1988, p. 18)

Ou seja, permitir-se a ação estatal ao arrepio da lei importaria negar-se a afirmação primeira de nossa Constituição Federal, qual seja, de que “A República Federativa do Brasil (...) constitui-se em Estado Democrático de Direito” (art. 1º. “caput, da CF/88).

E mais, nunca é inoportuno repisar que Guarda Municipal não é Polícia.

Inclusive, nessa linha de constatação, o Egrégio Tribunal Paulista, ao julgar a ADIN no. 2272391-03.2021.8.26.0000 (em 17 de agosto de 2022), refutou a possibilidade de alteração de referida instituição para “Polícia Municipal”, “in verbis”:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.DECRETO AUTÔNOMO. ALTERAÇÃO DADENOMINAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPALPARA POLÍCIA MUNICIPAL. Normas constitucionais referentes à segurança pública que são de observância obrigatória pelos entes estatais subnacionais. Guarda municipal que não integra o rol das instituições responsáveis pela segurança pública no Brasil (caput do artigo 144 da Constituição Federal). Guardas municipais às quais se conferiu apenas a função de proteger bens, serviços e instalações municipais, obedecidos os preceitos da lei federal (§ 8º do artigo 144 da Constituição Federal e artigo 147 da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade configurada.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272391-03.2021.8.26.0000, da Comarca de São Paulo).

Desta feita, a atuação dos guardas como se policiais fossem afronta o disposto no artigo 144, §8º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, o art. 144, da CF/1988 é claro ao atribuir o policiamento ostensivo exclusivamente à Polícia Militar e a função investigativa compete à Polícia Civil, facultando aos Municípios a criação de Guardas Cíveis para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Como dito, não se desconhece que qualquer do povo pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como acima já disposto e como disciplina o Código de Processo Penal, em seu artigo 301.

Assim, patente a ilegalidade da ação dos guardas civis municipais.

Nem mesmo a Lei Federal de nº 13.022/2014, que estabeleceu as competências das Guardas Municipais, autoriza as guardas exerçam atividades típicas da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Nesse sentido, em ação direta de inconstitucionalidade de nº 154.743-0/0-00 (autos nº 9039481-58.2007.8.26.0000), o E. Tribunal Paulista deliberou que:

“(...) A faculdade outorgada aos municípios de criação de suas guardas não lhes

concede o direito de extrapolar os limites ali impostos, ou seja, visam unicamente a proteção de seus bens, serviços e instalações, devendo ser repelida qualquer tentativa de alargamento desse horizonte, quando mais se constatada invasão a outras esferas."

Em Recurso Extraordinário (nº 608.588/SP), ainda pendente de julgamento, contra mencionado "decisum", o ilustre Procurador-Geral da República, asseverou que:

"Estão fora das atribuições constitucionais das guardas municipais as atividades que extrapolem a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, como as de policiamento ostensivo fora desse contexto, as de polícia judiciária e a apuração de infrações penais".

Desta feita, atento ao princípio da legalidade estrita, aplicável aos agentes estatais, bem como ao disposto no §8º, do art. 144, da CF/1988, concluo pela ilegalidade na atuação dos guardas municipais no caso presente.

Devemos ainda recordar que a localização posterior de drogas (e aqui não importa a quantidade) não é capaz de excluir a ilegalidade já perpetrada.

Refuto aqui a afirmação dos guardas em juízo de que detinham autorização de outro morador do imóvel. Isso porque, nenhuma menção nesse sentido havia sido feita em solo policial, restando evidente que se trata de declaração tendente a justificar a ilegalidade cometida.

Ademais, ainda que se trata-se de mero esquecimento dos servidores na fase de investigação, sabe-se que a simples afirmação dos agentes estatais no sentido de que tiveram autorização do morador (no caso, o suposto delator apócrifo), sem que seja por ele confirmada em juízo e/ou perante a autoridade policial (ou por outro elemento idôneo, tal qual gravação ou autorização por escrito), não pode ser considerada válida.

Nesse sentido:

"(...) A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor (...)." (STJ, 6a. Turma, HC 598.051 - SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 02 de março de 2021).

Havendo controvérsia acerca da existência da autorização, cabe ao Estado provar sua existência, sob pena de ser tida como ilegal:

"Tráfico de drogas Controvérsia sobre a existência de autorização para ingresso na residência Recente posicionamento do STJ no sentido de que cabe ao Estado comprovar a autorização Prova, nestes autos, inexistente, sendo que a dúvida deve favorecer a Defesa Obtenção de parte da prova por meios ilícitos Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio Reconhecida a ilicitude da apreensão dos entorpecentes encontrados na residência do acusado Desconsideração de tais provas para o exame da conduta do réu Remanesce o fato de ter sido abordado, em via pública, com 2,2g de crack Inexistência de comprovação do intuito de comercialização Desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal Aplicada pena de advertência sobre os efeitos das drogas" (TJSP, 12a Câmara de Dir Criminal, Apelação Criminal nº 1501121-45.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria Des. Amable Lopez Soto, em 08 de julho de 2022).

No caso acima mencionado, restou assim consignado pelo Exmo Des. Relator,

"(...) Aqui, como visto, no que toca ao ingresso dos policiais no imóvel referido na denúncia, há controvérsia que a prova não resolve com o necessário critério de certeza.

Dúvida que não pode ser resolvida com base na afirmação de que depoimento de policial goza de presunção de idoneidade a ponto de preponderar sobre a prova de defesa.

In casu, a dúvida quanto à dinâmica dos fatos não pode ser resolvida a favor da Acusação. Pelo contrário. Se o Ministério Público não logra demonstrar de forma inequívoca a legalidade do ingresso de policiais na casa de quem quer que seja, a diligência deve ser declarada ilícita. A dúvida, como cediço, deve favorecer o réu. (...)”

Resta, assim, evidente ser ônus do Estado a demonstração de que houve prévia autorização para ingresso na residência, que não pode ser admitida válida simplesmente com os depoimentos dos agentes estatais envolvidos na ocorrência.

Nesse sentido, o E. STJ

"(...) BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL (...)” (STJ, HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a. Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021)

"Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior, 6ª. Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Assim sendo, em razão de tantas ilegalidades, tem-se como ilícitas as provas obtidas e juntadas aos autos, ensejando a inexorável absolvição do denunciado.

No que se refere ao crime do art. 329, do Código Penal, a improcedência é também de rigor, eis que a oposição (se, de fato, houve) não foi contra ato legal dos guardas, mas contra ato ilegal por eles perpetrado, conforme exaustivamente demonstrado acima.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS, já qualifico nos autos, por falta de provas em relação ao crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e por atipicidade da conduta em relação ao crime do art. 329, do Código Penal, com base no artigo 386, incisos III e VII, do CPP, nos moldes da fundamentação.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, bem como a devolução ao réu dos demais bens apreendidos. Oficie-se.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, inclusive certidão de honorários.

PRIC.

Araras, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA